

1503292-62.2020.8.26.0536  
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos  
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Magistrado: Thais Cristina Monteiro Costa Namba  
Comarca: São Vicente  
Foro: Foro de São Vicente  
Vara: 1ª Vara Criminal  
Data de Disponibilização: 11/10/2022  
... Data de registro: 09/08/2016).

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33, CAPUT, E 35 DA L. 11343/06). Pretensão de desconstituição do julgado, para absolvição do réu. Deferimento parcial. Autoria e materialidade demonstradas com relação ao delito de tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Inexistência de provas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMARCA de São Vicente  
Foro de São Vicente  
1ª Vara Criminal  
Rua Jacob Emmerich, 1367, São Vicente-SP - cep 11310-906  
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503292-62.2020.8.26.0536 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:  
1503292-62.2020.8.26.0536  
Classe - Assunto:  
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Documento de Origem:  
Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2269762/2020 - 01º D.P. SÃO VICENTE, 2049/2020 - 01º D.P. SÃO VICENTE, 2269762 - 01º D.P. SÃO VICENTE, 2049/20/284 - 01º D.P. SÃO VICENTE  
Autor:  
Justiça Pública  
Réu:  
JOÃO PAULO DE OLIVEIRA SOUZA e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Thaís Cristina Monteiro Costa Namba

Vistos.

JOÃO PAULO DE OLIVEIRA SOUZA foi denunciado como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006, na forma do artigo 69, do Código Penal, c.c art. 61, inciso II, alínea "j", do último diploma legal, e MIRIAN MOURA DE BARROS foi denunciada como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, c.c art. 14, inciso II, do Código Penal, e no art. 35, caput, da Lei 11.343/2006, todos na forma do art. 69, do Código Penal porque, segundo narra a denúncia do Ministério Público, no mês de outubro de 2020, neste município e Comarca, os denunciados e o indivíduo até então conhecido apenas como "Neguinho" associaram-se para o fim de praticar tráfico de drogas.

Consta, ainda, que no dia 29 de outubro de 2020, por volta das 17h30min, na avenida Prefeito José Monteiro, defronte ao nº 1.078, em via pública, neste município e Comarca, em ocasião de calamidade pública, o denunciado JOÃO PAULO DE OLIVEIRA SOUZA transportava droga, para o fim de tráfico, sem autorização, e a denunciada MIRIAN MOURA DE BARROS tentou adquirir drogas, para o fim de tráfico, sem autorização.

As fls. 139/140 restou autorizada a quebra do sigilo de dados telefônicos dos réus. A denunciada Mirian ofereceu defesa preliminar às fls. 174/175.

O denunciado João Paulo ofereceu defesa preliminar à fl. 215.

Recebida a denúncia aos 25 de janeiro de 2021 (fls. 219/222).

Laudo de exame químico-toxicológico às fls. 244/246.

Houve audiência de instrução às fls. 303/304, oportunidade em que foram ouvidas testemunhas e interrogado o réu João Paulo.

Revogada a prisão cautelar do corréu João Paulo às fls. 374/376 e de Mirian às fls. 459/460.

Relatório a respeito de celulares apreendidos para fins de quebra do sigilo dos dados telefônicos às fls. 507/508.

Audiência exclusivamente para realização do interrogatório da ré Mirian à fl. 538/539.

Em memoriais substitutivos às alegações finais, o Ministério Público requereu a parcial procedência da pretensão punitiva, condenando-se réu João Paulo como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, c.c art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal e a condenação de Mirian Moura de Barros como incurso nas penas do no art. 33, caput, da c.c. art. 14, inciso II e 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal (fls. 543/551).

A defesa de João Paulo, por sua vez, pugnou pela improcedência da pretensão punitiva, absolvendo-se o réu. Subsidiariamente, requereu, em caso de condenação, o reconhecimento da atenuante da confissão, o reconhecimento da causa especial de diminuição do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, bem como a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Requereu, por fim, o direito de recorrer em liberdade.

A defesa de Mirian pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da agravante da calamidade pública, a incidência da atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria, o reconhecimento da causa especial de diminuição do §4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006, bem como a incidência do grau máximo de diminuição em relação à tentativa. Pediu, ao final, a fixação de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (fls. 570/577).

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

A pretensão é parcialmente procedente.

Materialidade delitiva veio comprovada com o auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão (fls. 07), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 244/246), bem como pela prova oral coligida nos autos.

A autora, por sua vez, é certa e aponta seguramente para o acusado João Paulo, até porque confesso.

Interrogado em juízo, João Paulo de Oliveira Souza disse que trazia consigo as drogas, porém desconhece Mirian. Esclareceu que combinou de entregar a uma pessoa a mochila com as drogas na frente do banheiro da rodoviária de São Vicente, sob promessa de pagamento de R\$1.000,00. A pessoa que o pagaria conhecia seu perfil. Disse que pegou a droga na estação de metrô Itaquera em São Paulo. Relatou que um colega seu conhece "Neguinho", o dono da mercadoria, e fez a proposta para ele levar a droga. Informou que estava desempregado e que tem dois filhos para criar. Fazia apenas bicos na firma de Rafael, sua testemunha. Disse que não foi registrado porque havia pouco serviço durante a pandemia. Relatou que no dia 30 deveria pagar a pensão do seu filho mais velho, Paulo Moisés, e no desespero e na necessidade aceitou a proposta. Disse que pegou a droga ao meio-dia na frente do banheiro da estação de metrô Itaquera e também o dinheiro da passagem. Relatou que deveria

chegar 17h30min e aguardar até 18h no máximo alguém pegar a mochila consigo na frente do banheiro da rodoviária de São Vicente e que essa pessoa saberia qual a cor das suas roupas e seu nome. Disse que essa pessoa seria um rapaz, que iria se apresentar como "menino do Neguinho", que lhe daria o dinheiro e pegaria a mochila. Desconhece Mirian. Nunca fez esse transporte antes. Relatou que o colega que lhe fez a oferta sequer mora no seu bairro, que o conheceu jogando bola e que teria comentado com ele a situação difícil pela qual passava. Afirmou que trabalhava também como vendedor no farol, porém nessa mesma semana perdeu sua mercadoria para a fiscalização. Viu-se sem saída e acabou por aceitar a oferta. O combinado era para estar 17h30min da tarde em frente ao banheiro da rodoviária, aguardar alguém lhe chamar e se apresentar como "menino do Neguinho" para então entregar a mochila. Disse que receberia R\$1.000,00 ou R\$250,00 por quilo de droga, sendo-lhe dito que havia quatro quilos na mochila. Também não conhecia o rapaz que lhe entregou as drogas em Itaquera. Foi orientado por esse rapaz a ir até a estação Jabaquara e pegar uma perua até São Vicente, porém não havia nenhuma perua, então resolveu pegar um Uber com outras três pessoas, duas moças e um rapaz que foi na frente. Disse que possui uma tatuagem no braço e outra na perna. Disse que, num primeiro momento, os policiais o abordaram na avenida da praia, no farol, e perguntaram-no de onde vinha e se estava trazendo mochila, ao que respondeu que sim, porém a moça do Uber falou que não, esquecendo-se que ela estava no porta-malas. Nessa indecisão os policiais pediram para ela encostar mais à frente e foi abordado por eles, já confessando que tinha uma mochila com drogas no porta-malas. Seu celular ficou no banco de trás. Disse que os policiais o detiveram por cerca de meia-hora e depois o conduziram à delegacia. Posteriormente, viu uma moça sendo conduzida também na delegacia e o perguntaram se era ela quem receberia a droga, sendo que respondeu negativamente, pois seria um rapaz que a receberia, desconhecendo a pessoa deles. Ficou sabendo posteriormente que Mirian foi presa pelo mesmo processo. Relatou que o "Neguinho" só falou consigo por celular, porque seu conhecido passou o número. Por telefone "Neguinho" deu detalhes da transação. Relatou que só fez isso porque precisava muito do dinheiro e que Rafael não poderia lhe adiantar nenhum pagamento. Pediu dinheiro para outras pessoas que também não podiam lhe emprestar. Não teve contato com ninguém por whatsapp de nome Mirian (fls. 303/305 - mídia armazenada no SAJ).

Interrogada em juízo, a ré Mirian Moura de Barros disse que não são verdadeiros os fatos narrados. Disse que não ia receber a droga, mas tinha uma dívida com "Neguinho" de R\$50,00 e não tinha condições de pagá-la. Afirmou que "Neguinho" propôs que ela entregasse R\$250,00 para o réu João Paulo, a troco de quitar sua dívida com ele, ao que aceitou. Nega que fosse pegar a droga, pois ela seria entregue na mão de outra pessoa. Afirmou que até ser presa não sabia que se tratava de dinheiro para pagar droga. Relatou que só soube que a droga seria entregue para outra pessoa após ser presa. Nunca foi processada anteriormente e trabalha atualmente como cozinheira na cidade de Praia Grande. Às perguntas do Ministério Público, respondeu que contou a "Neguinho", com quem tinha dívida, que não iria pegar droga na mão, mas que poderia levar os R\$250,00 para entregar ao menino. Afirmou que "Neguinho" esclareceu que não precisaria pegar nenhuma droga. Relatou que não sabia que a pessoa que receberia R\$250,00 fosse lhe encontrar portando as drogas. Nega que fosse pegar a droga, mas sabia que o dinheiro que estava levando dizia respeito a uma negociação de drogas (fl. 539 - mídia armazenada no SAJ). Ouvido em juízo, a testemunha Wesley Castelhão da Silva é policial militar e disse que, no dia dos fatos, recorda-se de um veículo Fox vermelho trafegando pela Avenida Prefeito José Monteiro, sendo que a motorista se chamava Neusa e o passageiro João Paulo. Ao perceber a viatura ao lado do veículo, João Paulo virou o rosto, o que soou estranho, parecendo um roubo. A placa do veículo era de São Paulo e a motorista se mostrava muito nervosa. Decidiram pela abordagem dos ocupantes e, após revista pessoal, João Paulo teria dito que havia droga em uma mochila que estava no porta-malas do veículo e que a pertencia. Informou, ainda, que morava em São Paulo e que havia pego a droga para entregar a uma moça de nome Mirian, que estaria esperando para recebe-la na rodoviária de São Vicente, ganhando com isso R\$250,00. Pegou a droga no Jabaquara, totalizando quatro tabletes e meio de

maconha. Foi solicitado apoio de outra equipe para fazer a abordagem de Mirian na rodoviária. A equipe o fez, abordou a suspeita e foi informado que foi encontrado com ela o valor em espécie. Foi dada prisão em flagrante de ambos. Disse que o réu informou aos policiais que mantinha contato com Mirian pelo celular e mostrou a foto dela. Relatou que achou suspeita a atitude do réu em virar seu rosto, quando o veículo em que estava emparelhou com a viatura, não querendo mostrá-lo. Quanto à motorista, após abordagem notou-se que o aparente nervosismo era na verdade o jeito da condutora. afirmou que o João Paulo informou durante a revista pessoal que a havia uma mochila no porta-malas contendo drogas e que seria dele. Disse que Neusa informou ser motorista do aplicativo "bla-bla car" e que já havia deixado outro passageiro anteriormente a João Paulo, mas não demonstrou espanto ao ver o ocorrido. Relatou que, durante a abordagem, só havia Neusa e João Paulo no veículo. Informou que João Paulo lhes confessou que conhecia Mirian tão somente pela foto do aplicativo whatsapp, não a conhecendo de outras datas, e o trâmite da transação do tráfico se iniciava com o contato de um rapaz, que passava o contato na baixada santista para João Paulo entregar a droga e pegar o valor em espécie. Esclareceu que foi outra equipe que abordou Mirian, enquanto o depoente permaneceu com João Paulo e Neusa. As equipes só se juntaram na delegacia (fls. 303/305 - mídia armazenada no SAJ).

Ouvido em juízo, a testemunha Alexandre Pachioni, policial militar, disse que estava em patrulhamento quando a equipe do policial Castelão pediu apoio, explicando a situação, que teria abordado um indivíduo com entorpecentes, cerca de quatro tabletes e meio de maconha, e que iria entregar para uma moça chamada Mirian na rodoviária de São Vicente. Deslocaram-se até a rodoviária e, de posse do nome e das características passadas, fizeram a abordagem. Disse que a ré confessou estar aguardando uma pessoa vindo de São Paulo e que tinha a quantia de R\$250,00 para entregar para o rapaz. afirmou que ficaria com a droga e que a levaria para a região do Bitaru. Não informou para quem ia a droga, nem tampouco quanto receberia por isso. afirmou que Mirian disse só conhecer João Paulo para realizar o ato de traficância (fls. 303/305 - mídia armazenada no SAJ).

Ouvido em juízo, a testemunha Pedro Ulisses Bento Junior, policial militar, disse que estava de motorista da equipe do Sgt. Pachione e foi solicitado pela equipe do Sgt. Castelão apoio na rodoviária de São Vicente, a fim de localizar Mirian. Foram até o local, abordaram Mirian e com ela foi encontrada R\$250,00. Disse que Mirian confessou de pronto que aguardava um rapaz para entrega do entorpecente e que ele receberia a quantia de R\$250,00. afirmou que Mirian fez contato com João Paulo exclusivamente para realizar a transação da droga (fls. 303/305 - mídia armazenada no SAJ).

Ouvido em juízo, Divaldo Antônio da Silva, policial militar, disse que se encontrava com a equipe do Sgt. Pachione, quando a equipe do Sgt. Castelão solicitou apoio para localizar uma pessoa na rodoviária, de nome Mirian. Chegando ao local, localizaram a pessoa e ela confessou que tinha R\$250,00 e que receberia drogas (fls. 303/305 - mídia armazenada no SAJ).

Ouvida em juízo, a testemunha Neusa Moreira da Costa, motorista de aplicativo, disse que trouxe quatro pessoas de São Paulo, do metrô de Jabaquara. Uma pessoa desceu no canal 1, e uma mãe estava acompanhada de uma adolescente, que pediram para descer em uma faculdade, ficando por último o réu João Paulo. Relatou que se tratava de um rapaz de estatura pequena. Disse que estava entrando sentindo Centro de Convenções de São Vicente, saindo da rua Manoel da Nóbrega para entrar na rua Marechal Deodoro, quando foram abordados. Disse que o rapaz estava no banco de trás, no lado direito, e foram abordados por policiais. Disse que os policiais conversaram com o rapaz, que mencionou haver uma mochila no porta-malas, mas logo foram liberados. Mais à frente, na rua Prefeito José Monteiro, os policiais mandaram-na parar e ficar bem afastada do réu. Um dos policiais veio perguntar a ela se conhecia o rapaz, quando ela disse que o réu se tratava de um passageiro e que ela trabalhava como motorista de aplicativo. afirmou que essas quatro pessoas do carro não se conheciam, à exceção da mãe filha, que ficaram na faculdade. São cobrados preços fixos, cada pessoa paga trinta e cinco reais. Não conhecia o réu antes. afirmou que visualizou o réu com uma mochila quando ele embarcou no veículo

em São Paulo. Normalmente é perguntado se o passageiro quer levar consigo a bagagem ou se quer que coloque no porta-malas, ao que o réu optou por colocar no porta-malas. Afirmou que visualizou os policiais abrirem a mochila, mas não deu para ver o que estava saindo da mochila. Os policiais a informaram no local da abordagem que se tratava de quatro quilos de droga. Disse que quando foi parada pela primeira vez, imagina que os policiais a deixaram seguir porque havia apenas duas faixas na rua, sendo que a abordagem poderia bloquear o trânsito, então deixaram seguir e a abordaram logo adiante, num local mais amplo. Disse que entendeu que, na primeira abordagem, poderia seguir e que perguntaram ao réu se ele tinha algo consigo, sendo que o rapaz respondeu que havia uma mochila no porta-malas (fls. 303/305 - mídia armazenada no SAJ).

Essas foram, pois, as provas produzidas sob o crivo do contraditório, das quais exsurge indubitável a autoria do réu João Paulo em relação ao crime de tráfico de drogas, mas não ficou bem delineada a materialidade sobre Mirian. Durante seu interrogatório, o corréu João Paulo confessou a prática do tráfico de drogas, fornecendo a justificativa de que passava dificuldades financeiras. Afirmou que conheceu um colega em jogo de futebol e lhe contou as dificuldades que passava no momento. Este colega teria lhe dito que um terceiro apenas identificado como "Neguinho" estaria procurando um interessado para prestar um serviço. Forneceu seu número de telefone a esse colega, que o repassou a "Neguinho", que entrou em contato com o acusado.

Disse que tomou conhecimento do intuito de "Neguinho", que não era outro senão contratá-lo para o transporte de drogas, da cidade de São Paulo até São Vicente. Afirmou que por ter dois filhos para sustentar e, ainda, diante do cenário pandêmico que se instalou à época dos fatos, tornando a inserção no mercado formal de trabalho mais difícil, viu-se sem alternativas e resolveu aceitar a proposta. Esclareceu que "Neguinho" lhe pagaria R\$250,00 por cada quilo de droga transportada, sendo que lhe foram confiados cerca de 4kg. Combinou de se encontrar com um preposto de "Neguinho" na estação de metrô de Itaquera e lá recebeu a mochila contendo drogas, além do dinheiro da passagem para se deslocar até São Vicente.

Tomou a condução de um veículo de aplicativo até o seu destino, que seria a rodoviária de São Vicente, e lá deveria se encontrar até às 18h com uma pessoa que lhe faria contato pessoalmente. Antes de chegar ao destino final, entretanto, foi abordado por policiais militares, que o detiveram em flagrante na posse da mochila que continha entorpecentes, a qual estava acondicionada no porta-malas do veículo conduzido pela motorista de aplicativo.

A corré Mirian, por sua vez, informou que devia dinheiro a "Neguinho", no valor de R\$50,00, mas não tinha condições de pagá-lo. Para quitar a dívida, "Neguinho" propôs que Mirian levasse R\$250,00 até um rapaz, na rodoviária de São Vicente e, após, perdoaria sua dívida. Assinalou que só aceitou a proposta de "Neguinho" sob a condição de que não encostaria em droga alguma e que não sabia que o rapaz que receberia o dinheiro estaria também transportando entorpecentes.

Os policiais militares responsáveis pelas prisões em flagrante dos réus prestaram depoimento unânime e harmônico. A equipe do sargento Castelhão, que funcionou como testemunha nestes autos, patrulhava pela cidade de São Vicente quando emparelhou a viatura com um veículo de placas de São Paulo no trânsito. Notaram que havia no interior do veículo uma parte feminina na condução, que demonstrava algum nervosismo, e o réu João Paulo na parte de trás, o qual, ao visualizar a viatura, tentou esconder o rosto, atitude essa que, somada ao aparente nervosismo da motorista e o fato do veículo ser de outra cidade, motivou à conclusão de que havia fundada suspeita de que o caronista trazia consigo arma ou algum objeto ilícito. Assim, procedeu-se a busca pessoal dos indivíduos e constatou-se, de pronto, que o réu João Paulo trazia consigo, em uma mochila guardada no porta-malas do veículo, cerca de 4kg de maconha.

Em entrevista pessoal ao acusado, foi-lhes dito que o destino da mochila seria a rodoviária de São Vicente, onde lá marcou o encontro com uma pessoa na frente do banheiro, sob promessa de pagamento, e que toda a transação seria combinada pelo celular. De posse do nome e das características de Mirian, a guarnição do sargento

Castelão solicitou apoio à guarnição chefiada pelo sargento Pachioni, que também funcionou como testemunha nestes autos, logrando essa encontrar a acusada na rodoviária.

Afirmaram que a ré confessou estar aguardando uma pessoa vinda de São Paulo para fazer a entrega de R\$250,00, a troco de receber drogas. Diante dos fatos constatados, foi conduzida à Delegacia de Polícia.

Por fim, a testemunha Neusa Moreira da Costa, motorista de aplicativo que levou o réu João Paulo de São Paulo a São Vicente confirmou que este embarcou na estação de metrô Jabaquara, com destino à rodoviária da cidade litorânea e que trazia consigo uma mochila, a qual lhe pediu para guardar no porta-malas do veículo. Não tinha ciência do conteúdo da mala, mas confirmou que era mesmo de propriedade do réu. Só soube que se tratava de droga quando foi informada pelos policiais.

Sendo assim, a confissão do corréu João Paulo quanto ao crime de tráfico de drogas se coaduna com as prova oral colhida nos autos. Evidentemente que as dificuldades financeiras não constituem justificativas suficientes ou mesmo causa de excludente de ilicitude para a prática espúria do crime de tráfico de drogas, sob pena de indevida descriminalização ou despenalização do tipo que, sabidamente, traz consequências nefastas à sociedade, razão pela qual a imputação do crime de tráfico de drogas restou bem demonstrada em relação ao corréu João Paulo.

Já no que concerne a Mirian, entendo que as provas coligidas nos autos não são suficientes para o decreto condenatório do crime de tráfico de drogas.

Por certo que o crime em comento (tráfico ilícito de drogas, na modalidade “adquirir”) é unissubsistente, isto é, consuma-se com um único ato de execução, que seria o instante em que o dinheiro ou coisa que o valha é entregue a alguém, não admitindo fracionamento da conduta e, por corolário lógico, a modalidade tentada. Neste sentido, já decidiu o C. STJ:

(...) o entendimento dominante na doutrina e na jurisprudência é no sentido da impossibilidade da tentativa de tráfico de entorpecentes, pois o tipo penal do art. 33 da Lei de Tóxicos se constitui em crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, bastando a prática de apenas uma das ações previstas na norma para que se configure o delito de tráfico, ficando assim afastada a possibilidade de tentativa do crime”(5ª Turma - AgRg no Resp nº 1676696/MG, Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA - j. 26.9.17).

Analisando a conduta perpetrada pela corré Mirian, verifico que a acusada foi detida ainda na posse do dinheiro que em tese deveria ser entregue ao corréu João Paulo. Este, por sua vez, sequer chegou ao destino para que houvesse a possibilidade de receber os valores pelo transporte da droga.

Em outras palavras, a corré Mirian não percorreu o iter criminis até os atos executórios, estes sim, puníveis nos termos do art. 33, da Lei 11.343/2006, permanecendo sua conduta no campo dos atos preparatórios, enquanto detinha a posse dos valores que se destinariam ao pagamento pelo transporte do entorpecente, em local onde se daria a transação.

No intuito de explicar a transição dos atos preparatórios para os atos executórios, a teoria objetivo-formal, segundo Cleber Masson, diz que ato executório “é aquele que se inicia a realização do verbo contido na conduta criminosa. Exige tenha o autor concretizado efetivamente uma parte da conduta típica, penetrando no núcleo do tipo”.

O fato de a corré Mirian estar na posse dos valores que seriam entregues a João Paulo, por si só, não se confunde com o verbo “adquirir”, nem tampouco ofende o bem tutelado pela norma contida no art. 33, da Lei 11.343/2006, de modo que sua conduta é atípica e não transpõe os meros atos preparatórios, não se podendo falar também em tentativa.

Em função de fatos semelhantes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS TENTADO. ABORDAGEM POLICIAL INTERCEPTOU EVENTUAL ENTREGA DE DROGA. AGRAVADO NÃO TEVE A POSSE DO ENTORPECENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO DE EXECUÇÃO.

ITER CRIMINIS NÃO INICIADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, INTERPOSTO COM IDÊNTICOS FUNDAMENTOS. 1. As instâncias ordinárias consignaram que a abordagem policial flagrou reunião entre o Agravado com corréu, que detinha a posse da droga. 2. De acordo com o entendimento jurisprudencial desta Corte, o fato de o Agravado ser flagrado reunido com pessoa que portava droga não configura o início do iter criminis, uma vez que o entorpecente não esteve em momento algum em sua posse. Tal situação poderia caracterizar, no máximo, ato preparatório, o que é impunível. Precedentes. 3. Agravo regimental do Ministério Público Federal desprovido. Julgo, outrossim, prejudicado o agravo regimental do Ministério Público Estadual. (AgRg no AgRg no HC 554.166/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 19/11/2020).

Em arremate, o laudo de exame químico-toxicológico atestou que a substância apreendida às fls. 244/246 se tratava de TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante da lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020).

Desta feita, a forma como estavam acondicionadas, a quantidade e a confissão dos réus conduzem à certeza de que a substância encontrada se prestava ao tráfico ilícito, daí porque não há de se falar na absolvição dos acusados.

Quanto ao crime de associação para o tráfico, tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343/06, verifica-se que o tipo penal exige prova da estabilidade e permanência entre os integrantes do grupo, de modo que, para a comprovação da materialidade, é indispensável o ânimo associativo de forma estável e duradoura, com a finalidade de praticar tráfico de drogas.

No caso dos autos, embora a denúncia mencione que os acusados se associaram para a prática deste delito com um terceiro denominado "Neguinho", nada há nos fólios que justifique tal assertiva.

O fato de serem abordados em um contexto conexo não indica necessariamente a associação para o tráfico, podendo caracterizar apenas a prática do crime em concurso.

Nesse sentido:

Apelação Criminal. Artigo 35, "caput, da Lei 11.343/06 e Artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal. Absolvição. Necessidade quanto ao delito de associação para o tráfico. Conjunto probatório insuficiente à condenação. Não comprovação da estabilidade. Delito de dano Comprovado - Sentença retificada. Apelos providos. Expedição de alvarás de soltura clausulados em favor dos réus" (Apelação0003553-18.2014. Relator(a): Borges Pereira; Comarca: Boituva; Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento:09/08/2016; Data de registro: 09/08/2016).

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33, CAPUT, E 35 DA L. 11343/06). Pretensão de desconstituição do julgado, para absolvição do réu. Deferimento parcial. Autoria e materialidade demonstradas com relação ao delito de tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Inexistência de provas quanto a possível liame subjetivo do acusado com o adolescente. Para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei de Drogas, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. Entendimento consolidado e pacífico dos tribunais superiores e deste E. Tribunal. Ausência de demonstração, in casu, da associação estável, que não se confunde com a coautoria (art. 29, CP). Decisão manifestamente contrária à evidência dos autos e ao texto legal. Dosimetria. Em razão do redimensionamento da pena decorrente da absolvição, mostra-se cabível a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, já que preenchidos os requisitos legais. Réu que era primário e sem Maus antecedentes, sem prova de que se dedicava à atividade criminosa ou integrava organização ou associação para o tráfico. Cabimento, ademais, da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Revisão criminal parcialmente deferida. (TJ-SP - RVCR: 22388524620218260000 SP 2238852-46.2021.8.26.0000, Relator: Marcelo

Semer, Data de Julgamento: 17/05/2022, 7º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/05/2022).

TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Prova segura da autoria e da materialidade do crime de tráfico. Versões dos réus isoladas no quadro probatório e infirmadas pelos relatos seguros dos policiais militares. Condenações por este delito inafastáveis. Crime de associação não comprovado. Inexistência de prova da estabilidade da associação, a indicar a existência de mera coautoria. Absolvição de rigor quanto a esta infração. Penas do tráfico adequadas. Básicas acrescidas de um sexto diante da causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06. Correta a negativa da aplicação do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, diante da dedicação à atividade criminosa. Regime fechado necessário. Impossibilidade de substituição das penas corporais por restritivas de direitos. Inviabilidade da detração. Apelos parcialmente providos para absolvição dos réus quanto ao delito de associação para o tráfico. (TJ-SP - APR: 15001735520198260560 SP 1500173-55.2019.8.26.0560, Relator: Tristão Ribeiro, Data de Julgamento: 10/08/2020, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/08/2020).

Assim, diante da ausência de elementos que indiquem a estabilidade da relação criminosa entre os réus e, considerando que a dúvida deve sempre implicar benefício ao acusado, de rigor a absolvição dos réus em relação ao delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, por insuficiência do conjunto probatório formado nos autos. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva, apenas para o fim de condenar o réu João Paulo como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, absolvendo-se Mirian das imputações que lhe foram dirigidas na denúncia.

Nessas condições e partindo do mínimo legal, passo à dosimetria e individualização da pena de João Paulo, com observância do sistema trifásico (art. 68 do CP).

Na primeira fase da dosimetria da pena, verifico que o réu é portador de maus antecedentes, cf. autos nº 0033115-11.2011.8.26.007, com data da condenação transitada em julgado em 24/07/2014.

Anote-se que a extinção da punibilidade em 25/10/2019 calcada nos arts. 107, IV e 110, do CP, não tem o condão de afastar os maus antecedentes, porquanto a sentença condenatória transitou em julgado, sendo certo que o reconhecimento da prescrição da pretensão executória resulta apenas na impossibilidade jurídica de se exigir o cumprimento da sanção penal imposta na sentença, subsistindo, de outro lado, os efeitos secundários da condenação, de modo a ensejar o reconhecimento dos maus antecedentes.

É portador de maus antecedentes, também, por ocasião da condenação exarada nos autos nº 0027556-36.2014.8.26.0050, com trânsito em julgado para a defesa em 29/08/2014 (fl. 31).

Ademais, a quantidade de droga apreendida e atribuída aos acusados (3.8kg - fl. 245) foge à normalidade do tipo, ensejando uma multiplicidade de porções que podem ser encaradas como verdadeiro comércio varejista da droga.

Sendo assim, considerando os múltiplos fatores a serem considerados como valoração negativa das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 59 do CP e 42 da Lei 11.343/2006, elevo a pena-base em 1/3, totalizando 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, presente a agravante da reincidência, cf. autos nº 0012666-78.2017.8.26.0635, com data de trânsito em julgado para a defesa em 02/06/2020 (fls. 30/31). Presente, ainda, a confissão espontânea.

Considerando o quanto decidido no Tema 585, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não", promovo a compensação integral das circunstâncias agravante e atenuante, mantendo-se o patamar anteriormente adotado.

Por fim, rechaço o reconhecimento da agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, sob pretexto do crime ter sido praticado em ocasião de calamidade pública. Respeitado entendimento diverso, alinho-me à interpretação de que, para a configuração dessa agravante, exige-se a demonstração



de que o infrator, de algum modo, prevaleceu-se dessa situação fática para a prática do crime.

E o que se viu foi justamente o contrário. A pandemia da COVID-19 trouxe mais pobreza e desigualdade social, colocando a economia do País em colapso, retirando-se dezenas de milhares de empregos formais do mercado de trabalho em razão do isolamento social, fato esse público e notório, o que motivou as pessoas a se colocarem no mercado informal do labor, respeitando ou não o isolamento social, condição esta última que somente foi agraciada aos mais privilegiados.

Sendo assim, entendo que não há nenhum nexo causal entre o estado de calamidade que vivenciamos em razão da pandemia do COVID-19 e a prática do delito de tráfico de drogas, na perspectiva de facilitação ou prevalecimento da situação desastrosa que a sociedade atravessou, motivo pelo qual fica rechaçado, com a devida vênia, o reconhecimento dessa agravante.

Na terceira fase da dosimetria da pena, ausentes causas de aumento e diminuição de pena. Anote-se que o redutor previsto no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006 deve ser afastado, em função da reincidência e dos maus antecedentes ostentados pelo réu.

Ausentes outros motivos que ensejem a modificação do quantum fixado, torno definitiva a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Analisando as peculiaridades do caso concreto, especialmente, a reincidência do réu e a quantidade de droga apreendida, nos termos do art. 33 e 59 do CP e 42, da Lei 11.343/2006, fixo o regime inicial de pena como o fechado.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, além do sursis penal, nos termos do artigo 44, incisos I e II, e artigo 77, caput e inciso I, do Código Penal.

Diante da ausência de elementos para se aferir a situação econômica do acusado, fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do montante do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Detração e eventual progressão de regimes constituem institutos próprios da execução penal, e em tal âmbito devem ser aferidos, ainda mais porque para a progressão se faz necessário o exame de requisitos subjetivos do reeducando, não disponíveis ao Juízo do processo de conhecimento, sem falar que tal providência implicaria também em ofensa ao princípio do Juiz natural.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva, para o fim de CONDENAR JOÃO PAULO DE OLIVEIRA SOUZA como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, às penas de 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado, bem como para ABSOLVÊ-LO da imputação referente ao art. 35, da Lei 11.343/2006, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP; e ABSOLVER MIRIAN MOURA DE BARROS referente à imputação do art. 33, da Lei 11.343/2006, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP, bem como para ABSOLVÊ-LA da imputação referente ao art. 35, da Lei 11.343/2006, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Em virtude de terem respondido ao processo soltos, por ocasião da revogação da prisão cautelar no curso da ação, poderão recorrer nesta condição, se por aí não estiverem presos.

Oportunamente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Por fim, decreto o perdimento do dinheiro apreendido em favor do FUNAD.

Como trânsito em julgado, oficie-se, com as cautelas de estilo e lance-se o nome do réu João Paulo no rol dos culpados.

Determino a incineração dos entorpecentes apreendidos, oficiando-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

São Vicente, 11 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA